

1500407-76.2021.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO INADMISSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS AUMENTO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ART. 28, DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

3ª Vara

Praça Martinho Funchal de Barros, nº50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500407-76.2021.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500407-76.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082913/2021 - DEL.POL.GARÇA, 16980035 - DEL.POL.GARÇA, 443/21/204 - DEL.POL.GARÇA, 2082913 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKE LUAN CAMILO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

MIKE LUAN CAMILO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do crime descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de março de 2021, por volta de 20h05min, na Rua Santana, n. 951, Bairro Labienópolis, nesta Cidade e Comarca de Garça (SP), o acusado, mantinha em depósito, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 2 (dois) tijolos de maconha, com peso bruto de 1.233,98 gramas, conforme Auto de Exibição e Apreensão (fl. 8), Laudo de Constatação (fls. 34/36) e Exame Químico Toxicológico - Definitivo (fls. 85/88), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, na data dos fatos, Policiais Militares do Batalhão de Ações Especiais (BAEP) de Bauru (SP), foram designados para realização de

patrulhamento ostensivo pelo Município de Garça (SP), visando coibir o alto índice de criminalidade e a repressão ao tráfico de drogas, quando receberam informações da polícia militar local de que o indivíduo conhecido por MIKE, estaria praticando tráfico de drogas em sua residência.

Os policiais dirigiram-se até a residência indicada e lá chegando se depararam com várias pessoas fazendo um churrasco. Todos foram abordados e revistados, mas nada de ilícito foi encontrado. Na sequência, MIKE foi interpelado sobre a prática de tráfico de drogas no local, mas nada informou. O autuado autorizou a realização de buscas no interior da residência, bem como levou os policiais ao seu quarto. Novamente questionado se havia algo de ilícito no local, MIKE desta vez confessou aos policiais militares que estava na posse de dois tabletes de maconha, indicando inclusive o local onde a droga estava escondida, qual seja, o seu guarda-roupa.

A droga foi localizada, apreendida, pesada e periciada. Interrogado, o autuado negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que o entorpecente encontrado em seu guarda-roupa não era de sua propriedade. Entretanto, os tijolos de maconha foram localizados em seu quarto, mais precisamente em seu guarda-roupa, sendo que, informalmente, disse aos policiais que a droga era para seu uso pessoal, o que denota que o entorpecente lhe pertencia.

Diante das circunstâncias fáticas, entendo que o tráfico de drogas restou caracterizado. Isso porque já pesava contra o acusado denúncia de que estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Além do mais, a quantidade de maconha encontrada em seu guarda-roupa é totalmente incompatível com a condição de usuário.

Devidamente citado, o réu ofertou defesa prévia (fls. 104/105).

A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2021 (fls.112).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, bem como realizado o interrogatório do acusado, conforme mídia anexa nos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal para condenar MIKE LUAN CAMILO nos termos da denúncia. A defesa de MIKE LUAN CAMILO alegou, preliminarmente, nulidade de provas em razão da invasão domiciliar. No mérito, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28.

É o relatório
Fundamento e decido.

Primeiramente, não há que falar em ilicitude das provas colhidas em solo policial. No caso em análise, conforme se extrai do depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, houve a autorização de ingresso pelo acusado na residência. Não há qualquer razão para desacreditar a palavra dos policiais neste ponto.

No mais, é cediço que a inviolabilidade do domicílio é afastada em virtude do estado de flagrância, tal como na hipótese dos autos e nos exatos termos do art. 5º, XI, da CF/88.

Sobre o tema, já decidiu o C. STJ: "Com efeito, cumpre esclarecer que é desnecessário mandado de busca e apreensão quando o agente se encontra em estado de flagrância, mormente em razão do que preceitua o artigo 5º, incisos XI e LXI, da Constituição Federal, nos quais se encontram permissivos excepcionais de violação do domicílio e de restrição da liberdade do indivíduo em razão de flagrante delito. E há que se ter presente que o paciente foi acusado da prática de crimes de

natureza permanente, quais sejam, tráfico de entorpecentes na modalidade "[...] ter em depósito, [...] ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar "; e receptação na modalidade "ocultar, em proveito próprio [...] coisa que sabe ser produto de crime".(...) Desse modo, extrai-se das passagens acima que é dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se trata de flagrante delito, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio" (STJ, HC 188.195/DF, 5ª Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. 27.09.2011)

E não é outro o entendimento do E. TJSP: "TRÁFICO DE DROGAS PROCESSOPROVA ILÍCITA INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMEPERMANENTE HIPÓTESE EM QUE O AGENTE PERMANECE EM ESTADO DE FLAGRANTEENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE A CONDUTAANTERIOR DO RÉU JUSTIFICOU A AÇÃO POLICIAL EM SUA MORADIA E A BUSCA FOIAUTORIZADA POR SEU GENITOR PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGASINSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ABSOLVIÇÃO INADMISSIBILIDADE PALAVRAS DOS AGENTESDA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOSMATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS CONDENAÇÃOMANTIDA RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICAÇÃOPARA PORTE PARA USO PRÓPRIO INADMISSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUENÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO NARCOTRÁFICO CONDENAÇÃO MANTIDARECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS AUMENTO DA PENA-BASEEAFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 CONDENAÇÃOANTERIOR PELO DELITO DO ART. 28, DO MESMO DIPLOMA INADMISSIBILIDADE INFRAÇÃODE MENOR POTENCIAL OFENSIVO SEM COMINAÇÃO DE PENA PRIVATIVADE LIBERDADEOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RECURSO MINISTERIAL NÃOPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500162-86.2020.8.26.0561; Relator(a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro:21/07/2021)

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente as provas coligidas nos autos, entendo que é o caso de desclassificação da conduta do acusado para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade do crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006 foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/02); pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); pelos termos de depoimentos em solo policial (fls. 06/07, 13 e 17); pelos documentos (fls. 22/27); pelo laudo pericial (fls.34/36); pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

Em solo policial, a testemunha THIAGO NAKAZAWA DE SOUZA declarou: "Que, a respeito dos fatos, tem a esclarecer que é policial militar do BAEP0 de Bauru/SP, e que nesta data foram designados para fazer patrulhamento ostensivo na área do 09 BPMI pelo Município de Garça/SP, em razão do alto índice de criminalidade no Município, principalmente o tráfico de entorpecentes, que assim estavam em patrulhamento pela cidade, quando de posse de informações dos policiais militares locais de que naquela Rua Santana, de que um indivíduo de nome Mike estava praticando tráfico de entorpecentes no local; que chegando ao local, estavam presentes diversas pessoas fazendo um churrasco, onde foram todos abordados e feito revista pessoal; que o indivíduo Mike, identificado como um dos proprietários da residência, foi indagado sobre o tráfico de entorpecentes no local, e ele disse que não havia nada a informar; que ainda foi solicitada a este indivíduo a autorização para fazer uma busca no local, e ele autorizou e os levou aos seus aposentos; que perguntado a ele se havia algo de ilícito no local, e ele disse que estava na posse de dois tabletetes de entorpecente, aparentando ser "maconha"; que ainda indicou o local onde estavam, ou seja, dentro de seu guarda roupa; que os tabletetes foram pesados neste plantão

aferindo a quantia de 1.233,98; que ele informou ainda que eram de uso pessoal, mas em razão de seus antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes e ainda roubo, o declarante deu voz de prisão ao referido indivíduo apresentado nesta Delegacia de Polícia para as providências de praxe; que o depoente afirma que não conhecia o autuado presente, ainda que ele não reagiu à prisão captura, os familiares acompanharam o procedimento.” (fl. 06). EM JUÍZO, relatou que: “que faziam patrulhamento da cidade de Marília e se dirigiram à cidade de Garça em razão das informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas naquela região; que quando entraram na rua supracitada e visualizaram uma residência com várias pessoas festejando, dentre elas o acusado. Que após abordagem, Mike foi indagado sobre tráfico de drogas que permitiu a entrada de policiais e disse que havia drogas no local para seu consumo, os quais foram encontradas no guarda-roupa do acusado. O local é habitado por várias pessoas. A droga estava em dois tabletes, possivelmente para a venda, baseando-se na quantidade e pela maneira embalada; que as denúncias eram de que estava ocorrendo tráfico de drogas naquela região. Não havia denúncias de tráfico específica contra o réu; que na casa havia mais pessoas, mas nada de ilícito foi encontrada com elas; que trabalha em Bauru há 1 ano no batalhão de ações especiais e que nunca trabalhou em Garça. Afirmou que é Comandante de equipe. Antes da abordagem realizavam o patrulhamento, chegando ao local indicado como ponto de venda de drogas; que a prisão do réu foi feita pela sua viatura; Foi autorizado pelo próprio acusado a ingressar na residência, não tendo providenciado autorização por escrito. O acusado negou o tráfico, afirmando que tinha drogas para o consumo pessoal. Afirmou que estavam em 3 policiais, e que na residência estavam o acusado, sua tia e seus sobrinhos; que no quarto do réu, foi encontrado pelo depoente e outro policial, tendo o acusado acompanhado a busca; que a droga foi encontrada no guarda-roupa entre as roupas do réu, não sabendo precisar em que lado ocorreu a apreensão da droga. O acusado confessou a propriedade da droga. Informaram o acusado que ele poderia permanecer calado. Afirmou que as informações passadas pelos policiais de Garça eram de que havia tráfico de drogas no local por indivíduos e que uma das pessoas que participava seria Mike; que não foi feita campana na frente da residência do réu; que foram avistados vários indivíduos, não tendo sido encontrado nada ilícito. Não foi encontrada balança de precisão e nem anotações. As informações que recebeu sobre o tráfico de drogas na região chegou naquele dia. Não se recorda da embalagem da droga apreendida.”

Em solo policial, a testemunha DIEGO RAFAEL MAGESTE confirmou a versão do colega de farda (fl. 13).

Durante o interrogatório em solo policial, o acusado MIKE LUAN CAMILO declarou: “Que a respeito dos fatos apurados neste procedimento de Polícia Judiciária, o interrogando tem a esclarecer que nesta data estava ocorrendo um churrasco entre seus amigos e família, com aproximadamente dez pessoas; que no início da noite chegaram os policiais militares de outra cidade os quais não conhece, e abordaram todas as pessoas e fizeram revista pessoal; que um dos policiais militares o perguntou se havia algo em sua residência; esclarece que o local é uma residência coletiva, sendo que moram no local quatro famílias; que não informou que havia substância entorpecente em sua residência, e que foi surpreendido com a ação da polícia militar, pois não é traficante; que já foi preso por furto e quando adolescente apreendido pela prática de tráfico de entorpecentes; que quanto ao fato dos policiais terem encontrado dois tabletes de maconha em seu guarda-roupa, afirma que não são de sua propriedade”. (fl.14). Durante o interrogatório judicial, o acusado manifestou desejo de apenas responder as perguntas de seu defensor, afirmando que: “na ocasião dos fatos estava fazendo churrasco com mais dez pessoas quando os policiais chegaram, mas que nada de ilícito foi encontrado. Que não autorizou a entrada dos policiais na residência e que os policiais não permitiram que seus familiares acompanhassem a abordagem. Negou ser proprietário da droga.

Pois bem. Após análise do acervo probatório, entendo que não ficou devidamente

demonstrado que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas a consumo de terceiros.

Conforme se extrai da prova oral coligida em juízo, o acusado estava em sua residência com várias pessoas durante evento festivo, quando houve a abordagem da polícia militar.

Durante a inquirição em juízo, o policial militar THIAGO NAKAZAWA DE SOUZA, em resposta a indagação formulada pela acusação, afirmou que não havia denúncia específica contra o acusado no tocante à prática do crime de tráfico de drogas e que o acusado negou o cometimento de tal crime, limitando-se a afirmar que possuía droga em seu guarda-roupa, onde foi efetivamente encontrada, e que esta seria destinada ao consumo pessoal.

É necessário observar ainda que, somente após questionamento da defesa e indicação de contradição com o depoimento prestado em solo policial, foi que THIAGO NAKAZAWA DE SOUZA afirmou que havia denúncia específica contra o acusado.

O policial em questão afirmou ainda que não foram localizadas balança de precisão e anotações aptas a comprovar o tráfico ilícito de drogas e que também foi realizada campana no local.

Outrossim, impende destacar que, em resposta à pergunta formulada pela acusação, o policial militar THIAGO NAKAZAWA DE SOUZA afirmou que a localização de dois tabletes de maconha indicava possivelmente o tráfico de drogas.

Contudo, a meu ver, a localização de drogas em poder do réu, sem a presença de outros elementos concretos hábeis a indicar a comercialização de drogas, impedindo a condenação do réu pelo crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

É importante constar que não foram ouvidas outras testemunhas em juízo para confirmar a acusação descrita na denúncia.

Nesse contexto, dadas as circunstâncias da apreensão, não se evidenciou a prática de tráfico. Todavia, caracterizado está o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Observa-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306).

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco: "APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM".POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIACOMPROVADAS.CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USODE ENTORPECENTES. NÃO HOUE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART.28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO.IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da

Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Pelos argumentos acima entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Comprovadas autoria e materialidade e levando-se em conta os elementos concretos do fato, entendo que deva ser aplicada a pena de advertência ao acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para desclassificar a imputação contida na peça inicial acusatória e condenar MIKE LUAN CAMILO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE ADVERTÊNCIA.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Após o trânsito em julgado, realize as anotações de praxe e, se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono constituído por meio do convênio OAB/DPE.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Garça, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA